

1500272-49.2020.8.26.0185

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mateus Lucatto De Campos

Comarca: Estrela D'Oeste

Foro: Foro de Estrela D'Oeste

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... da conduta de associação para o tráfico; pela insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas, com a desclassificação para o delito previsto no art. 28, "caput", da lei de drogas; subsidiariamente, pediu o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada - art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06. Por fim, a defesa do réu Tiago também pediu sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Estrela D'Oeste

Foro de Estrela D'Oeste

1ª Vara

Rua Minas Gerais, s/n, Estrela D'oeste-SP - cep 15650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500272-49.2020.8.26.0185 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500272-49.2020.8.26.0185

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212083/2020 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE, 13243120 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE, 192/20/601 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE, 2212083 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

GABRIELA DOS SANTOS DE JESUS NOGUEIRA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Lucatto De Campos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu "denúncia" em face de GABRIELA DOS SANTOS DE JESUS NOGUEIRA, já qualificada nos autos, como incurso nos arts. 33, "caput", e 35 "caput", ambos da lei n. 11.343/06, em concurso material e na forma do art. 2º da lei n. 8072/90 - Lei dos Crimes Hediondos; bem como em face de TIAGO PEREIRA DE SOUZA, também com qualificação nos autos, como incurso no art. 35, "caput", da lei n. 11.343/06. Narra a denúncia que, no dia 27 de agosto de 2020, por volta das 13:23 horas, na Rua Mato Grosso, próximo ao terminal rodoviário - Centro, na cidade de Estrela d'Oeste/SP, a denunciada GABRIELA DOS SANTOS DE JESUS NOGUEIRA trazia consigo, para fins de tráfico, 19.85g de cannabis sativa L ("maconha") sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também que, desde data incerta até o dia 27 de janeiro de 2021, nos

municípios de Estrela d'Oeste e Américo de Campos, os denunciados GABRIELA DOS SANTOS DE JESUS e TIAGO PEREIRA DE SOUZA, juntamente com Leonardo Aparecido de Souza Nogueira; Mariana Aparecida Carvalho Santos; Mayara Cristina de Carvalho Amorim da Silva; e João Luiz Batista de Carvalho, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06. A denúncia veio acompanhada de elementos colhidos na fase investigativa e foi recebida em 09 de março de 2021 (fls. 717ss). Relevante esclarecer que as investigações policiais ocorreram simultaneamente à interceptação telefônica judicialmente autorizada que tramitou perante este juízo, objeto do procedimento distribuído sob n. 1500357-35.2020.8.26.0185, que está apensado a estes autos. Pontuo, ainda, que os investigados/acusados Leonardo Aparecido de Souza Nogueira; Mayara Cristina de Carvalho Amorim da Silva; e João Luiz Batista de Carvalho celebraram "acordo de não-persecução penal" com o Ministério Público (fls. 1294ss). Citados (fls. 818; e 1032), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 851ss; e 891ss). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas. Os réus foram interrogados. Finda a instrução, as partes apresentaram suas razões finais (fls. 1299ss; 1312ss; e 1347ss). O Ministério Público pediu a procedência integral da ação penal, argumentando que a prova produzida comprova a materialidade e a autoria dos delitos imputados aos acusados. Por sua vez, a defesa da corré Gabriela pela atipicidade da conduta de associação para o tráfico; pela insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de drogas, com a desclassificação para o delito previsto no art. 28, "caput", da lei de drogas; subsidiariamente, pediu o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada – art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06. Por fim, a defesa do réu Tiago também pediu sua absolvição; em preliminar argumentou pela ilicitude das provas produzidas; no mérito, sustenta que não há provas da materialidade, negando que o acusado estivera associado com os demais corréus para a prática do tráfico de drogas.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, respeitado o entendimento do nobre Defensor, entendemos que a objeção preliminar formulada pela defesa do corréu Tiago deve ser afastada. Com efeito, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas foi devidamente submetida ao crivo judicial e, obviamente, fundamentada na legislação específica, de modo que não há de se falar em nulidade. Nesse sentido, embora o acusado não tenha sido "alvo" da interceptação, entendeu o órgão ministerial que os elementos angariados eram suficientes para deflagração da ação penal, sendo que, a efetiva suficiência (ou não) dos elementos de prova colhidos são atinentes, em momento distinto, ao mérito em si da pretensão penal, e como tal será analisado. Assim, não houve qualquer espécie de "desvio" no encetamento da diligência, ocorrendo, em verdade, verdadeiro encontro fortuito de elementos probatórios relacionados a outro agente ("serendipidade subjetiva"), em que autoridade policial angariou, por ocasião dos lícitos procedimentos e de forma casual, elementos pertinentes a outros agentes, que estavam na linha de desdobramento normal da investigação. Aliás, são devidamente similares os fatos investigados e ofensivos ao mesmo bem jurídico. A hipótese descrita, assim, não gera nulidade, notadamente considerando que, na hipótese dos autos, há conexão entre as infrações e não é possível estabelecer de plano todos os envolvidos em eventual "associação criminosa". Além disso, não há também de se falar em incompetência territorial deste juízo. Com efeito, o fato que desencadeou as investigações foi a prisão em flagrante da acusada Gabriela – por tráfico de drogas, ocorrida nesta comarca (Estrela d'Oeste), sendo que referida acusada também residia em município que integra a competência deste juízo (São João das Duas Pontes/SP). Assim, embora os demais corréus residam em comarca diversa, há conexão com os fatos aqui apurados, pois o delito de associação foi praticado pelos corréus em concurso – art. 76, I, do CPP; e a prova das circunstâncias da "associação" pode influir na prova do tráfico de drogas – art. 76, III, do CPP. Não obstante, observa-se que o acusado não apresentou "exceção de incompetência" deste juízo (apenas argumentou para fundamentar o pedido de nulidade das interceptações), de modo que, ainda que eventualmente os tribunais superiores entendam pela incompetência deste juízo, não haverá nulidade das provas produzidas, vez que a jurisprudência do C. STJ já consagrou a chamada "teoria do juízo aparente", de modo

que a superveniente alteração de competência do juízo, não implica em ilegalidade no aproveitamento de provas colhidas ou autorizadas por magistrado aparentemente competente para processar e julgar o feito (AgRg no HC 668.544/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Passo ao mérito.

A pretensão penal deduzida em juízo é parcialmente PROCEDENTE. Com efeito, finda a instrução probatória, entendemos que a autoria e materialidade vieram demonstradas a contento apenas com relação ao delito previsto no art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06, sendo o caso de absolvição quanto ao delito de "associação para o tráfico" - art. 35, da lei n. 11.343/06. Neste ponto, a materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (fls. 01ss); boletim de ocorrência (fls. 20ss); auto de exibição e apreensão (fls. 23ss); laudo de constatação (fls. 27ss); laudo de exame químico-toxicológico (fls. 78ss); e, notadamente, pelas provas orais colhidas na fase investigativa e em contraditório judicial. De igual modo, a autoria de GABRIELA está configurada. Vejamos.

O Delegado de Polícia RAFAEL LATORRE COSTA, em juízo, disse que a investigação teve início com a prisão da acusada Gabriela; que dois policiais militares capturaram Gabriela próximo ao terminal rodoviário de Estrela d'Oeste/SP, sendo que ela trazia consigo 04 (quatro) porções de "maconha"; que duas porções estavam embaladas, uma na forma de cigarro e outra no interior de um "dichavador"; que também foi apreendida uma balança de precisão e o aparelho de celular dela; que obtiveram autorização judicial para quebra do sigilo telefônico dela, sendo que, após realização de perícia, o laudo apresentou conversas nas quais Gabriela negociava a compra e venda de drogas com colegas de Américo de Campos, Pontes Gestal e Votuporanga; que então foi elaborado um relatório de investigação onde foi identificado Leonardo, Mayara, Mariana, Tiago Pereira e João Luiz; que então realizaram interceptação telefônica, e nas escutas foi corroborado que Gabriela era o elo deles na compra e venda de drogas; que ele pediu para Mariana ir buscar drogas para ela, e que ela revendia para os comparsas e usuários de Américo de Campos; que muitos usuários chamavam ela no WhatsApp para que utilizassem drogas; que eles falavam muito em "fumar um" na praça de Américo de Campos, e que lá ela negociava a porção de drogas; que ela não tinha ocupação lícita e vivia do comércio de droga; que ela foi apreendida com uma grande quantidade em dinheiro, cerca de R\$700,00 (setecentos reais); que na data Gabriela foi buscar drogas em Jales para entregar para Mariana; que também captaram a ligação de João Luiz que falava abertamente na compra e venda de "balas", mas não conseguiram concluir se era "cocaína" ou "ecstasy"; que fazia referencia a 181 (cento e oitenta e uma) porções que estavam escondidas; que João Luiz e Tiago Pereira vendiam a droga; que também captaram na interceptação telefônica que Leonardo abastecia Gabriela quando ela estava sem drogas, sendo que Mariana buscava a droga para ela; que há uma ligação em que Gabriela pede para Mariana buscar certa quantidade de droga com Leonardo; que depois Mariana liga e confirma que já estava na posse da droga; que Mayara não era alvo principal da investigação, mas descobriram que ela intermediava para Leonardo; que Mayara e Leonardo viviam em união estável, e na casa deles foram encontradas porções de drogas; que Gabriela e Mariana conversavam com Mayara, sendo que ela repassava a informação para Leonardo; que Tiago e João Luiz tinha relação direta com Leonardo; que na conversa entre João Luiz e Leonardo faziam referência ao auxílio de Tiago na compra e venda da droga; que na casa de Mayara e Leonardo encontraram pequenas quantidades de "maconha", restando eles presos em flagrante pelo tráfico de drogas; que as conversas indicam que eles são usuários, mas praticam o tráfico de drogas para manter o próprio uso; que a expressão "salvar um" significava passar a droga um para o outro; que não houve interceptação direta do aparelho de Tiago.

A policial civil JAKELINE XAVIER DE SOUZA, em juízo, disse que se recorda de uma conversa de João com Leonardo, em que eles falam abertamente de quantidade de drogas, de quantas gramas e porções entregues para terceiros; que esta foi a conversa mais específica, que dá a entender uma parte de gerenciamento; que nesta conversa eles citam Tiago, falando que eles três tem mais acesso ao "mocó", que é o

lugar onde fica guardada a droga; que eles falam que em determinado local teriam feito a separação da droga que iria para cada um, sendo que assim se dá a entender que Leonardo, João e Tiago tem mais acesso a esse entorpecente; que Pâmela, Gabriela e Mariana estariam repassando a droga; que há conversas em que eles pedem para pegar "tanto" com o Leonardo e com Mayara; que Mayara era convivente com Leonardo e tinha mais ciência da movimentação; que Mayara é irmã de João; que esteve na equipe que realizou buscas na casa de Leonardo e Mayara, onde foi encontrado uma porção de maconha, uma pochete que aparentava ser utilizada para transporte, além de uma quantia de dinheiro; que há conversas em que as mulheres combinam de se encontrar para usar maconha juntas; que a apreensão de drogas com Gabriela foi feita pela polícia militar; que não realizaram interceptação telefônica no celular do Tiago, pois não identificaram um linha vinculada a ele; que eles falam "kits" para mencionar uma quantidade de droga; que não se recorda do que foi apreendido na casa de Tiago.

O policial militar RODRIGO DE PAULA PEREIRA, em juízo, disse que tinham informações que chegaria uma quantidade de droga para Mateus Grippe e Kaique, que uma mulher viria entregar para eles através de um mototaxista; que na data dos fatos estavam patrulhando próximo à rodoviária quando viram um mototaxista chegando na rodoviária com uma passageira; que a passageira a todo momento ficou olhando assustada para a viatura; quando ela desembarcou do mototáxi fizeram a abordagem, quando então localizaram balança de precisão, dinheiro e droga em sua bolsa; que ela disse que a droga era para consumo; que ela falou que tinha pegado em Jales/SP; que depois passaram a receber mais informações do tráfico na cidade de Estrela d'Oeste e São João das Duas Pontes; o mototaxista confirmou que eles vinham de Jales/SP; que tinha dois porções embaladas e uma "solta"; que também tinha um "dichavador".

O policial militar WHASHINGTON LUIS PEREIRA DOS SANTOS, em juízo, disse que na data dos fatos estava em companhia do policial De Paula, e que tinham informações de que chegariam entorpecentes com uma mulher, vinda da cidade de Jales/SP, para Kaique e Mateus Grippe; que em patrulhamento próximo à rodoviária encontraram a moto chegando ali, sendo efetuada a abordagem; que então encontraram com Gabriela duas porções de entorpecentes, um cigarro e um "dichavador", além de uma quantia em dinheiro e uma balança; que ela alegou que era para uso próprio; que ela disse que tinha vindo de Jales/SP; que não conhecia Gabriela dos meios policiais.

O policial civil THIAGO GOUVEIA DOS SANTOS, em juízo, disse que deu cumprimento ao mandado de busca na casa de Mariana e de Jefferson; que apreenderam algumas porções de maconha; que participou das escutas telefônicas; que eles trabalhavam em "rede", tendo drogas em várias cidades da região; que eles adquiriam a droga em Américo de Campos; que Leonardo fazia a distribuição; que as meninas faziam distribuições menores aos usuários diretos; que Leonardo era que fornecia, coordenava e gerenciava; que Leonardo tinha relacionamento com Mayara.

O policial civil RAFAEL PORTUGAL HADDAD, em juízo, disse que de cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu Tiago; que apreenderam duas porções de maconha e dois celulares; que trabalha na cidade de Américo de Campos/SP, sendo que já tinham informações do envolvimento dos réus Tiago e Gabriela com o tráfico de drogas.

A testemunha JESUEL DOS SANTOS, em juízo, disse que conhece Gabriela da cidade de Américo da Campos/SP; que ela é uma pessoa trabalhadora e cuida muito bem das crianças dela; que soube que ela fazia uso de drogas há alguns anos atrás; que ela deixou de morar em Américo de Campos por determinado período; que ela atualmente ela trabalha numa fábrica em Votuporanga/SP.

O informante JOEL NOGUEIRA, em juízo, disse que o acusado Leonardo é seu sobrinho; que Leonardo está trabalhando como "servente"; que ele faz uso de drogas, embora esteja tentando parar; que ele sempre foi de família boa e íntegra; que nunca ostentou lucros ou roupas caras; que Leonardo e Mayara moram juntos na cidade de Américo de Campos/SP; que Mariana é irmã de Mayara.

A testemunha MARA SOLANGE MOURA, em juízo, disse que conhece a acusada Mayara, pois residem no mesmo bairro; que Mayara teve filho recentemente; que não sabe dizer se ela trabalhava; que não conhece o réu Tiago.

A informante MARIA DE LOURDES DA SILVA, em juízo, disse que é amiga da acusada

Mariana; que ela trabalhou muito tempo na Usina, mas atualmente está trabalhando numa fábrica em Votuporanga/SP; que ele era usuária de drogas, mas ultimamente parou; que ela nunca demonstrou renda incompatível com o trabalho que exercia. A testemunha ELIAS JOSÉ DA SILVA, em juízo, disse que já trabalhou junto com o acusado João, como pintor, durante 05 (cinco) anos; que residem na mesma cidade; que ele nunca demonstrou vida incompatível com os rendimentos de pintor; que ele é usuário de "maconha"; que não conhece o réu Tiago; que ele não trabalhou fazendo balas.

A testemunha JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA, em juízo, disse que conhece o réu Tiago da cidade de Américo de Campos/SP, pois residem no mesmo bairro; que ele é uma boa pessoa e nunca ouviu falar nada dele; que ele trabalha junto com o irmão dele, numa empresa de café; que nunca ouviu falar que ele esteve envolvido com venda de drogas em Américo de Campos/SP; que já ouvir falar que ele é usuário; que não conhece João Luiz e Leonardo; ele nunca trabalhou com doces ou balas.

Os réus negaram os fatos.

A acusada GABRIELA DOS SANTOS DE JESUS NOGUEIRA, em juízo, disse que na data em que foi abordada pelos policiais havia acabado de sair de um programa e pego o "moto-taxi"; que comprou a balança naquele mesmo dia, tanto que estava na caixinha, do mesmo jeito que havia comprado na loja; que estava fazendo um curso de brigadeiro e iria utilizar ela; que a maconha utiliza quando faz "programa"; que não chegou a fazer matrícula no curso, apenas estava comprando as coisas para fazer o curso; que a droga era para consumo pessoal, pois é usuária e faz uso quando vai fazer "programa"; que também estava com um dichavador e um "paieiro" feito, pois eram para uso; que não oferece as drogas para pessoas com quem faz "programa"; que o dinheiro que foi apreendido era dinheiro de "programa"; que o programa não custa R\$700,00, mas a pessoa lhe ajudava todo mês; sobre as conversas interceptadas, diz que são todos usuários e sempre um "salva" o outro; que falava com Mariana e Leonardo apenas para usarem drogas juntos; que não faziam comércio, apenas usavam; que não tinha contato com Tiago ou João; que não sabe se Leonardo tinha contato com eles; que sempre estudou junto com Mariana; que na conversa do dia 24/11, quando se referem a "chinelo" estão realmente falando do calçado e não sobre drogas; que antes de morar em Estrela d'Oeste morava em Américo de Campos/SP; que é comum os usuários "salvarem" os outros; que tem relação muito próxima de Mariana e Mayara; que faz uso de drogas há 05 (cinco) anos.

O acusado TIAGO PEREIRA DE SOUZA, em juízo, disse que era amigo de Leonardo; que fumavam juntos e um "salvava" o outro; que Leonardo nunca pediu para vender drogas; que nunca falou com João Luiz sobre "kits" que seriam preparados para vender; sobre a conversa de João e Leonardo, disse que na cidade tem muitas pessoas com nome Tiago; que nem sabe o que significa "kit"; que nunca comprou drogas de Leonardo; que não sabe sobre "pino", pois apenas fumavam "baseado"; que não se lembra de cumprir medida socioeducativa na adolescência; que não tinha desavença com Leonardo ou João; que não conhecia as moças que estão sendo acusadas neste processo; que é usuário de "maconha", mas também "cheira pó"; que nunca "salvou" os demais usuários; que já fumou junto com Leonardo.

Pois bem. Da conjugação de todas estas assertivas, entendemos como comprovado o envolvimento de GABRIELA no encetamento do tráfico de entorpecentes – art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06. Como é cediço, nem sempre a polícia se vale de informações oficiais para flagrante de delitos, utilizando-se também de notitia criminis inqualificada (anônima) ou mesmo espontânea e informal abordagem de munícipes. Nesse sentido, o delito de tráfico de drogas via de regra é cometido de forma velada, às escuras, de modo que a denúncia anônima, as diligências em determinados pontos da cidade (popularmente conhecidos como "boca" de tráfico), ou mesmo a abordagem de indivíduos que, por seu histórico e informação de populares dando conta de ocorrência de delito, tem ligação ao mundo das drogas ilícitas, são formas de se apreender entorpecentes, efetuar flagrante, e dar cabo de investigações e inquéritos policiais, nos termos do art. 5º, §3º do CPP.

Na hipótese versada nos autos, os policiais já tinham recebido denúncias de populares indicando que uma mulher iria trazer drogas para dois indivíduos da cidade de Estrela d'Oeste/SP, inclusive mencionando especificamente a rodoviária

local como ponto de encontro. Na data dos fatos, os policiais militares avistaram um mototaxista deixando a acusada Gabriela na rodoviária da cidade (aliás, Gabriela residia na cidade vizinha de São João das Duas Pontes e não em Estrela d'Oeste, nada explicando o porquê da parada), sendo que ela demonstrou certo nervosismo com a aproximação da viatura. Em razão disso, fora efetuada a abordagem, sendo então localizadas 19.85g de cannabis sativa L ("maconha"), embaladas de formas variadas (2 porções embaladas, um cigarro de maconha e uma pequena porção à granel de maconha; fls. 24); além de uma balança de precisão e a quantia de R\$705,85 (setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em espécie. E os informes produzidos não admitem outra conclusão, senão pela configuração do delito de tráfico de drogas. De fato, a quantidade de entorpecentes encontradas em poder da acusada, além das circunstâncias da apreensão, revela indubitavelmente a destinação ao comércio e a consequente configuração do delito previsto no art. 33, "caput" de lei n. 11.343/06.

Veja-se que a acusada admite a propriedade do entorpecente apreendido, refutando, apenas, o intento comercial. Entretanto, entendemos inviável o reconhecimento de mero status de usuário (pretendida desclassificação para a figura do art. 28, "caput" da Lei de Drogas). Isto porque não se contempla como conduta compatível com o status de usuários, a quantidade de droga apreendida (suficiente para confecção de vários cigarros); os demais materiais apreendidos (balança de precisão); a quantia em dinheiro apreendida (sem comprovação de origem lícita); além de alguns diálogos verificados em seu aparelho celular. De início, em relação à quantidade de drogas, entendemos que não pode ser considerada diminuta a quantidade de "maconha" apreendida, pois apta a gerar uma infinidade de unidades para consumo individual, considerando-se a necessidade de aproximadamente 01 (uma) grama para confecção de um cigarro ou "baseado". Cito precedente: "apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (Fonte: Apelação n.0000152-73.2017.8.26.0286 5ª Câmara Criminal de São Paulo j.26/10/2017)" (STJ; HC 590818-SP; Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; Data da Publicação: 29/06/2020).

Adiante, também restou injustificado o encontro da balança de precisão no mesmo contexto, sendo usual a localização de objetos desta natureza em circunstâncias da prática de tráfico de drogas, notadamente por se tratar de instrumento destinado ao fracionamento exato do entorpecente que será comercializado. Por outro lado, descabida e desarrazoada a tese de realização de "curso de brigadeiro". Com efeito, a acusada não demonstrou ter feito a inscrição em qualquer tipo curso (não apresentou qualquer matrícula ou outro documento comprobatório, sequer tratativa em rede social); não demonstrou a aquisição de qualquer outro material para tanto (ingredientes; outros utensílios domésticos; etc.); além disso, pouco soube explicar do porquê não realizou e concluiu efetivamente o suposto curso após ser colocada em liberdade. Portanto, inverossímil sua alegação.

Em seguimento, a acusada também não demonstrou a origem lícita dos valores apreendidos no contexto da traficância. Com efeito, na data da abordagem a acusada possuía a quantia de R\$705,85, sendo que tal montante estava em notas variadas e fracionadas (notas de \$100; \$50; \$20; \$10, \$5 e \$2; além de moedas de \$1 e 25, 10 e 5 centavos). Ao justificar os valores, a acusada afirmou que parte era decorrente de "programa" que havia feito, além de uma "ajuda" dada pelo suposto cliente.

Entretanto, novamente entendemos que a acusada não fornece a versão verdadeira. Com efeito, em diálogo captado durante as interceptações telefônicas, há menção de que o valor do "programa" da acusada equivalia a R\$100,00 (cem reais) – fls. 456 (conversa com Wilson), de modo que há relevante diferença entre o valor cobrado e o valor apreendido. Há ainda outro diálogo em que a acusada pede antecipadamente para um cliente a quantia de R\$20,00 (vinte reais) para comprar "maconha" (fls. 458), o que denota que eventuais "ajudas" recebidas pela acusada não chegam perto do valor apreendido com ela, tudo a permitir a conclusão de que se trata de proveito econômico proveniente do tráfico de drogas.

Frise-se, ainda, em consonância com o dominante entendimento jurisprudencial, que o

crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na estrita prática de atos de mercancia para a sua configuração. Vale dizer, tratando-se de "tipo misto alternativo", enquanto não encetado o comércio, a acusada praticava a ação nuclear "trazer consigo"; por outro lado, houvesse êxito em surpreender eventual concretização de transação, incorreria no verbo "vender", sendo ambos suficientes para configuração do delito. Neste sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). Portanto, de rigor a condenação de ambos os acusados pelo delito de tráfico de drogas – art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06.

Por outro lado, entretanto, entendemos que a mesma solução não pode ser dada quanto ao delito previsto no art. 35, "caput", da lei n. 11.343/06 – "associação para o tráfico". Com efeito, o delito em questão exige para sua configuração demonstração inequívoca que os envolvidos estavam associados com ânimo definitivo e de maneira estável para a consecução da traficância. E na presente hipótese, entendemos que são diminutos (e insuficientes) os elementos de convicção que indicam que os réus agissem de maneira estável e com vínculo permanente. Neste ponto, em relação à acusada GABRIELA, da leitura dos relatórios de interceptação telefônicas entendemos que as conversas captadas mais se aproximam de contatos com o intuito de encetarem o uso coletivo de entorpecentes e não o comércio ativo e permanente de entorpecentes. Aliás, o consumo coletivo de drogas poderia eventualmente ensejar a tipificação do art. 33, §3º, da lei n. 11.343/06, entretanto, a possível prática deste delito mencionado (art. 33, §3º) não é idônea para configurar o tipo previsto no art. 35 da lei n. 11.343/06, uma vez que exige expressamente que a associação seja para prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei (ou seja, não menciona o art. 33, §3º). Aliás, há diálogos em que GABRIELA pratica atos típicos do tráfico de entorpecentes (a reforçar o entendimento pela condenação no art. 33, supra fundamentado), mas ao nosso ver sem indicativo de atuação conjunta com os demais corréus. Por exemplo, na conversa com a pessoa de "Stef Gomes" (fls. 162ss), a acusada faz a intermediação da venda de entorpecentes, dizendo que não tinha "baseado" para vender, mas que poderia "fazer o corre", mas sem nada que envolva os demais corréus. Do mesmo modo, no dia 08/12/2020 (fls. 456ss) há diálogo em que Gabriela pede para Mayara/Leonardo vender \$20,00 de maconha para Mariana, sendo que em verdade a droga era para ele, pois em seguida ela pede para Mariana buscar a droga pra ele e Mariana diz que irá utilizar uma parte da droga dela (irá "tirar um fino"). Ou seja, a sequência de diálogo indica Gabriela como "compradora" de Mayara/Leonardo, além de uso compartilhado com Mariana. O diálogo que menciona a entrega de um "chinelo" é deveras incomum e não explicado de forma convincente pela acusada, mas, não transparece, de plano e de forma inequívoca se tratar de um ato típico de traficância. Ainda que o fosse, trataria-se de situação isolada e que não conduz invariavelmente à conclusão de se tratar de atuação associada. Assim, em síntese, entendemos que a acusada praticava o tráfico de drogas, mas não há demonstrativo de que atuava em conjunto com os demais corréus.

Do mesmo modo, em relação ao acusado TIAGO, também entendemos que são poucos os elementos de convicção produzidos em seu desfavor. Vale dizer, não houve demonstrativo suficiente da prática reiterada de atos, de modo estável e permanente. Nesse sentido, a tese acusatória se baseia neste único diálogo, que sequer fora encetado diretamente com Tiago (João e Leonardo mencionam a pessoa de Tiago). Veja (fls. 462ss):

Joao: o irmão!

Maiara: pera aí.

Joao: o irmão!

Leo: e aí? deu certo aí?

Joao: aqui, eu embalei 6 kit pro Tiago

Leo: quantos?

Joao: 6

Leo: han.

Joao: E dois pro tio João. Sobrou 1 pino. entendeu?

Leo: Ahan.

Joao: fez a soma aí? Aí sobrou 50 g da pura, aí, o Tiago quer falar com você aqui.

Aí marcou 4:30 pode pá?

Leo: Falou mano.

Joao: É nós moço. Vou ajudar o tio João tramar no zap aí.

Leo: Falou mano. Cê deu um salve no mano lá irmão?

Joao: no qual?

Leo: no Wilian lá mano.

Joao: ah, esse cara é mó pá mano, sei lá mano, nem quis responder.

Leo: o loco.

Joao: sem maldade mano, ah de amanhã não passa essa fita não mano, pode pá, também tem o lucrinho meu aqui, qualquer coisa já passo esse lucrinho aí tá ligado?

Leo: falou.

Joao: pode pá?

Leo: falou.

Joao: vai na paz fi. falou fi, fica com Deus.

Leo: aqui, falar pra você, não tem um pedaço daquele chá verde aí, não sobrou não?

Joao: qual?

Leo: verdinho.

Joao: eu tenho aqui, eu tenho aqui o que eu tenho meu de fumar, só.

Leo: não sobrou outro pedacinho lá?

Joao: Não, aquele pedacinho eu tinha ajeitado 25 g lá tá ligado? aí cê tirou 20 reais pra Mariana.

Leo: Ah, acabou daquele verdinho então.

Joao: É, daquele verdinho não tem mais não.

Leo: Ah, tira umas 12 gramas então depois desse aí, deixa separado. Se o Tiaguinho subir manda ele ponhar lá no negócio que tem lá em casa lá.

Joao: pode pá então.

Leo: falou.

Joao: falou fi.

Leo: é nós. Guarda as coisa certo hein.

Joao: Pode pá. cê quer que tira as coisa hoje de lá? cê que que tira de hoje lá?

Leo: é, era bom né. Mas tinha que achar um lugar mió.

Joao: só mato.

Leo: Ah mato é moiado mano, vai esquentar muito.

Joao: ah, pega amanhã cedo uai.

Leo: não, tinha que pensar numa outra casa sem alugar aí.

Joao: Ah mano, eu não sei memo de verdade.

Leo: Não, mais só ponha lá, deixa lá memo hoje, pode deixar lá memo.

Joao: pode pá então.

Leo: falou.

Joao: tamo junto então irmão, fica na paz.

Leo: ou, e tira 25 do nego aí.

Joao: an?

Leo: 25 mano.

Joao: da comercial?

Leo: é mano, deixa também no coiso lá em casa lá.

Joao: beleza vou falar pra ele por lá. hora que ele subir.

Leo: falou.

Joao: falou tamo junto.

Entretanto, depois de tal diálogo, nenhuma outra diligência fora encetada. Vale dizer, não há maiores informações se Tiago comprou para revender ou se eles eram "sócios" no comércio de entorpecentes. Não há demonstrativo de que as transações com Tiago eram recorrentes ou se foi ato isolado. Enfim, não foram exauridas as diligências para esclarecer o verdadeiro vínculo entre os acusados. Não se está a

excluir a hipótese de que Tiago seja "traficante". Também não está afastada por completo a possibilidade deles estarem realmente associados. Entretanto, com base apenas nesse diálogo, não é possível alcançar tal conclusão (pela associação) com a certeza necessária para condenação. Como se sabe, a simples reunião esporádica é insuficiente para caracterizar o delito em questão. Nesse sentido:

"(...) Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 3. O Tribunal a quo, tendo reconhecido que a reunião do paciente e os demais corréus teria sido eventual, a admitiu como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. 4. Não havendo qualquer registro, quer na denúncia, na sentença condenatória, ou no aresto objurgado, de que a associação do paciente com os demais sete corréus teria alguma estabilidade ou caráter permanente, não há que se falar no delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero concurso de pessoas..." (HC 208.886/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 08/11/2011, DJe 01/12/2011). Assim, não tendo sido demonstrada a existência de ânimo associativo permanente, estável e minimamente organizado, a absolvição de ambos os acusados quanto ao delito previsto no art. 35 da lei n. 11.343/06, é a medida mais adequada. Verifico, portanto, que tão somente em relação à imputação autônoma do delito de tráfico de drogas - art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06, a versão da acusada GABRIELA, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Passo à fixação da pena.

Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ainda ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que não há circunstâncias judiciais em desfavor do réu. Nada aponta para culpabilidade que suplante as circunstâncias já previstas e valoradas pelo legislador no tipo penal em questão, sendo o réu primário, não ostentando condenação anterior com trânsito em julgado, inexistindo qualquer outro elemento prejudicial a ser considerado. Há, assim, de se fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, da mesma forma, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes que possam alterar a dosagem da pena. Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), também não há razão para alteração do quantum de pena.

Em tempo, entendemos inaplicável a redutora do art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06. O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Frise-se que tais requisitos são cumulativos, devendo todos estar demonstrados no caso concreto para sua aplicabilidade. Entretanto, na hipótese dos autos, depreende-se dos elementos produzidos que a acusada se dedicava ao tráfico de drogas, tendo intenso envolvimento com o tráfico de drogas e outros delitos semelhantes (como o "uso compartilhado" - art. 33, §3º, da lei 11.343/06). Vale dizer, foram captados diversos diálogos em que a acusada compra, venda, faz intermediação para venda, tudo a indicar que não se trata de "traficante de primeira viagem". Não se ignore, ainda, que "primariedade não se confunde com bons antecedentes. O réu é primário se não teve condenação criminal anterior. Tem bons antecedentes se ostenta vida pregressa limpa, bom conceito social, reputação ilibada, nenhum envolvimento com o crime." (STJ - RHC 4965 SP 1995/0052715-4). Na hipótese, como já dito, não se pode conferir à acusada o mesmo tratamento que se dispensaria àquele que comercializa pequena quantidade de entorpecente, não demonstrando se tratar de uma mera iniciante na seara criminal.

Enfim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) ANOS de RECLUSÃO e 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente

examinados (art. 33, § 3º, do CP), à condenação superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) de reclusão (art. 33, § 2º, "b"), bem como à não reincidência, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime SEMIABERTO. Por fim, incabível a concessão do sursis penal (CP, art. 77) ou da substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44), em razão do quantum de pena estabelecido (quantidade de pena ora aplicada supera os parâmetros máximos autorizados), além do que, tratando-se de crime hediondo, não há demonstrativo de que a aplicação de tais benesses sejam suficientes para reprovabilidade da conduta. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim faço para o fim de CONDENAR a acusada GABRIELA DOS SANTOS DE JESUS NOGUEIRA, já qualificada nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) ANOS de RECLUSÃO e 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

Por outro lado, ABSOLVO os acusados GABRIELA DOS SANTOS DE JESUS NOGUEIRA e TIAGO PEREIRA DE SOUZA, já qualificados, quanto à imputação do delito inscrito no art. 35, "caput" da lei n. 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por estarem em liberdade e não haver causa superveniente para decretação de prisão (art. 312, CPP), DEFIRO aos réus o direito recorrerem e aguardarem julgamento em liberdade.

Já houve determinação para destruição das drogas (fls. 52ss). Não comprovada a origem lícita, DECRETO a perda em favor da União dos valores apreendidos, com fundamento no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP, e no art. 63 da Lei nº 11.343/06. Reverta-se ao FUNAD a relação dos valores declarados perdidos para os fins de sua destinação, face ao art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/06. Da mesma forma, comprovada a utilização na prática do tráfico de drogas, DECRETO a perda em favor da União dos demais materiais apreendidos (celular; balança de precisão e etc.). Com o trânsito em julgado, remetam-se à SENAD a relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente, face ao art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

No mais, condeno os réus, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), observada eventual gratuidade processual. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Oportunamente, expeça-se guia de execução definitiva. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Estrela D'oeste, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA